

論房地合一稅新制下不動產借名登記 之課稅爭議和體系重構

——以兩則高雄高等行政法院判決為例*

康育睿**

目次

壹、前言	1
一、問題意識	1
二、案例事實	2
三、本件所涉爭點	2
貳、不動產借名登記契約之私法性質	3
一、借名登記契約之構造和定義	3
二、不動產借名登記契約之效力	4
三、代結論	10
參、不動產借名登記返還之實體法定性	12
一、房屋、土地「取得日」之認定與實益	13
二、借名登記返還得否切斷持有期間之計算	13
三、實務上就取得日認定之關鍵在於「權利延續性」	16
四、小結：借名登記返還應被認定為係移轉取得	18
肆、民事判決對稽徵程序之拘束力	18
伍、結論	19
參考文獻	21

* 授課學期：114-2；課程名稱：所得稅法專題討論；授課教師：柯格鐘教授；報告日期：2026 年 4 月 23 日。

** 國立臺灣大學法律學系碩士班財稅法學組一年級，學號：R14A21077。

壹、前言

一、問題意識

我國自 105 年 1 月 1 日施行房地合一所得稅新制（下稱房地合一稅），旨在防杜不動產短期投機炒作，落實居住正義與租稅公平。為達此立法目的，所得稅法明定按不動產「持有期間」之長短，課以最高 45% 之稅率。然而，此一依期間遞減之稅率結構，卻也誘發了納稅義務人透過操縱「取得日」與「持有期間」進行租稅規避之強烈動機¹。實務上，不動產借名登記契約因具備高度隱蔽性，常淪為納稅義務人規避稅負之工具。當事人間不僅常於事前利用借名登記隱匿真實產權歸屬，面臨房地合一稅之重稅時，更屢見借名人企圖以「終止借名登記返還」為由，主張其為實質所有權人，進而要求將取得日回溯至原始出資購買之時點，以適用免稅之舊制或較低之新制稅率。更甚者，為規避稽徵機關之實質審查，納稅人常利用民事訴訟採「處分權主義」與「辯論主義」之特性，透過雙方無實質爭執之「訴訟上和解」、「調解」或「認諾判決」，製造出「法院認證之借名返還」外觀，企圖藉此私法文書綑綁肩負「職權調查主義」與「實質課稅原則」之稅捐機關。

基此，本文擬以兩則高雄高等行政法院判決為中心，探究當不動產借名登記返還時，其在稅法實體上究應定性為「權利之延續」抑或「全新之取得」？並進一步探討，面對未經實質證據檢驗之民事和解筆錄，稽徵機關應如何透過層級化之證據審查標準與舉證責任之分配，以防堵「假性爭訟」對房地合一稅

¹ 實際上，我國不動產資本利得所得稅制，無論新制舊制，都呈現出累退之結果，然而其中新制的累退程度又比舊制更加嚴重。歸根究底係新制為抑制短期炒作而不論資本利得多寡，完全以持有期間長短決定其稅率，惟如此即造成「閉鎖效果」，對於高資產階級而言，其有長期囤房之能力，且可藉由拉長持有期間，輕鬆適用較低之比例稅率以賺取高額利潤。此外，在持有期間決定稅率之誘因下，不動產借名登記即成為高資產者進一步擴大租稅套利空間之工具。藉由將房地產借名登記於親屬或特定人之名下，借名人不僅能輕易累積持有年份以製造「閉鎖效果」、規避短期累進之重稅；更有甚者，納稅義務人可利用出名人之身分、戶籍、居住外觀，藉此獲取新制之自用住宅免稅額及優惠稅率。關於新舊制有效稅率及累退性之實證研究，可參：曾中信，台灣房地產資本利得稅之研究：有效稅率與累進性之分析，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫報告，計畫編號：NSTC112-2410-H031-074，頁 17-26，2024 年。

制與整體租稅公平之侵蝕。

二、 案例事實²

甲於民國 90 年出資購買 A 房地。嗣於民國 95 年，甲以「贈與」為原因，將 A 房地移轉登記予親屬乙。移轉登記完成後，乙將戶籍遷入，且 A 房地歷年之水電費、房屋稅與地價稅皆由乙繳納。民國 106 年間，甲欲收回 A 房地出售，遭乙拒絕。甲遂向法院提起「請求返還借名登記」之民事訴訟。為免訟累，兩造乃於民事法庭上達成「訴訟上和解」，乙同意將 A 房地移轉登記予甲。甲隨即持和解筆錄，以「和解移轉」為原因辦畢所有權登記。嗣民國 107 年，甲將 A 房地高價出售予第三人。甲認為自己自 90 年起即為實質所有權人，106 年的移轉僅是「物歸原主」，故認為適用舊制土地免納所得稅之規定，而未申報房地合一稅。經國稅局查獲後，認定甲之「取得日」為 106 年（和解移轉日），持有期間未滿 1 年，屬房地合一稅新制課徵範圍，除依 45% 稅率補徵本稅外，並裁處漏稅罰。甲不服，提起行政爭訟。

三、 本件所涉爭點

1. 「不動產借名返還登記」之實體法定性：

原告主張 106 年的和解移轉，本質上只是借名登記的「回復原狀」，並未創設新的財產權，不應被視為稅法上的「取得」與。

2. A 房地「取得日」與「持有期間」之認定：

原告主張取得日應追溯至原始出資購買之 90 年，持有逾 10 年，應適用舊制免徵土地財產交易所得稅。

3. 民事「和解筆錄」對稽徵機關之拘束力與客觀舉證：

原告主張民事法院之「訴訟上和解」與確定判決有同一效力，既已載

² 案例事實係結合改編自：高雄高等行政法院判決 108 年度訴字第 490 號、高雄高等行政法院判決 114 年度巡稅簡字第 1 號。

明返還房地，國稅局即應受其拘束，承認借名登記關係存在。

貳、不動產借名登記契約之私法性質

一、借名登記契約之構造和定義

關於借名登記契約，由於係我國民法典未有規範之「無名契約」，因此實務發展上，就借名契約之定義，即出現若干不同見解³：

採最廣義見解者，如最高法院 105 年台上字第 1897 號判決和最高法院 106 年台上字第 1157 號判決所指：「所謂借名登記契約，乃當事人約定，一方（借名者）經他方（出名者）同意，而就屬於一方現在或將來之財產，以他方之名義，登記為所有人或其他權利人之契約」；惟本文以為，此等見解射程過廣，定義與一般之委任契約幾無區別，借名契約之特徵將不易凸顯，而不利於後續法律效果之探究⁴。

亦有如最高法院 97 年台上字第 2445 號判決之見解，將借名登記契約之定義限縮於「在目的無違強制、禁止規定或悖於公序良俗，且原因正當之前提下」關此見解，本文認為其係將借名登記契約背後之「動機、目的」此等成立要件和其定性上有所混淆。

因此，借名登記契約較為合適之定義毋寧應如最高法院 99 年台上字第 2448 號判決所指：「當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約」，此等見解亦為現今最高法院⁵和多數學說所採之主流見解。

³ 主參：柯格鐘，借名行為之課稅，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫報告，計畫編號：NSTC 113-2410-H-002-147，頁 3-7，2025 年。

⁴ 關此，多數見解認為借名登記契約之法律效果應「類推適用」委任之規定，而非直接適用即可知，多數見解似亦不認為借名登記和委任契約在本質上並無二致，因此在定義上即有將之凸顯、區別之必要。

⁵ 相同見解，諸如：最高法院 106 年度台上字第 1363 號判決、最高法院 107 年度台上字第 414 號判決等等。

二、 不動產借名登記契約之效力

（一） 契約內容自由之界限

私法自治原則為現代民法之基石，賦予權利主體得依自由意志締結契約，並享有形塑契約內容之充分自由。基於此精神，國家法制原則上應避免對私人契約內容進行過度之規制與干預。惟契約內容自由並非漫無邊際之絕對權利。為維繫整體法秩序與社會公益，私人契約之形成仍須受客觀規範之節制。在我國民法體系下，此種對契約內容自由之例外限制，具體明定於民法第 71 條及第 72 條。

當契約內容抵觸第 71 條之「強制或禁止規定」，或違反第 72 條之「公共秩序或善良風俗」時，即跨越了私法自治之合法界限。國家法秩序透過前開強行法規與概括條款之設定，例外介入並審查、否定該契約之效力，藉以精準達成個人締約自由與整體社會公益間之衡平。

當契約之約定內容抵觸民法第 71 條之「強制或禁止規定」時，法律即強制否定該契約之效力，以貫徹強制或禁止之法意，維護法律秩序之無矛盾性⁶。而民法第 72 條之「公共秩序或善良風俗」係指既存於法律本身之價值體系或法律外之倫理秩序，其規範目的乃在不使法律行為成為違反倫理性的工具，即不能使違反法律本身價值體系或違反倫理的法律行為，具有法律強制性⁷。

此外，當事人形式上雖未為禁止規定所禁止之行為，但其行為之結果卻為該禁止規定立法意旨所要避免發生的，即所謂「脫法行為」。通說⁸認為在解釋禁止規定時，若同時探求其規定的立法意旨、目的，所謂脫法行

⁶ 王澤鑑，民法總則，修訂新版，頁 326，2021 年。

⁷ 王澤鑑，註 6，頁 340-342；陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，五版，頁 167-169，2023 年。

⁸ 王澤鑑，註 6，頁 338-339；陳自強，註 7，頁 165-166；陳聰富，民法總則，三版，頁 278-280，2021 年。

為的概念，並無獨立存在之空間。蓋禁止規定的目的，若係在禁止特定結果的發生，則不論其手段如何，均在禁止之列；反之，若禁止規定，僅在禁止透過特定形態的行為、特定形式的行為達成一定結果，而非禁止以其他方式達成該結果，不屬於該禁止規定所禁止之行為，即係合法之行為。是以脫法行為實際上僅係法律解釋之問題。

（二）實務見解

就不動產借名登記契約之效力，最高法院實務見解歷經顯著之演變，通常分為「內部效力」和「外部效力」兩個層面進行討論。

1. 內部效力

就不動產借名登記契約本身之有效性而言，最高法院早期之見解⁹係將此類借名人僅將登記名義移轉，出名人未有管理、使用、收益、處分權能之契約，定性為所謂「消極信託」。並認為除有「確實之正當原因」外，通常係出於通謀虛偽意思表示，且極易助長脫法行為之形成而屬無效。

至於所謂「確實之正當原因」，早期實務見解亦存有相當之分歧，最高法院 88 年度台上字第 2115 號判決採嚴格立場，認為以逃避稅負為目的所為之借名登記，有悖於公序良俗，不得認為具備正當原因，應屬脫法行為而無效；惟最高法院 92 年度台上字第 1054 號判決則持較為寬鬆之見解，認為旨在避免地價稅累進課徵所為之借名登記，屬節稅之範疇，並未違反法律之強制規定或公序良俗，依契約自由原則應屬有效。二者間顯現早期實務在「逃稅」與「節稅」之界分上，尚未形成一致之判斷標準。

而晚近之實務見解則已明顯轉向，揚棄以「脫法行為」為由

⁹ 最高法院 71 年度台上字第 2052 號判決、最高法院 80 年度台上字第 2284 號民事判決、最高法院 94 年度台上字第 907 號判決參照。

逕行否定借名登記契約效力之立場¹⁰，改採較為寬鬆之判斷框架，認為只要借名登記契約之目的或內容未違反強制或禁止規定，且無悖於公序良俗，依契約自由原則即應認定為合法有效之無名契約。最高法院 98 年度台上字第 76 號判決更進一步明確指出，借名登記契約在性質上應與委任契約同視，其內容若不違反強制、禁止規定或公序良俗，應賦予無名契約之法律效力，並類推適用民法委任之相關規定處理當事人間之權利義務關係。此轉變亦可見於最高法院 97 年度台上字第 2445 號等判決。

雖使晚近實務不再以脫法行為動輒否定借名登記契約之效力，惟就民法第 71 條、第 72 條之有效性審查，雖有諸如最高法院民事大法庭 108 年度台上大字第 1636 號裁定就非原住民借用原住民身分購買原住民保留地以規避土地管制法規之情形，依民法第 71 條規定認為無效之案例，然實際上，就基於規避稅負而為之不動產借名登記契約其有效性之審查，似未見實務有進一步之論述。

2. 外部效力

就出名人違反內部約定，擅將不動產移轉登記予第三人之行為效力，早期最高法院部分判決¹¹係採「無權處分說」，認為出名人違反借名登記契約所為之物權處分，對借名人而言構成無權處分，其效力應依民法第 118 條定之，並保留善意第三人依信

¹⁰ 學說上亦認為實務早期以「消極信託」或「脫法行為」宣告借名登記無效之見解係有所不妥，蓋脫法行為僅是描述性統稱，不得作為法律行為無效之單獨依據。法院應回歸民法具體規範為判斷，倘當事人約定為消極信託，實係因屬通謀虛偽意思表示，而依民法第 87 條第 1 項無效；至於若具備實務所稱「正當原因」，則應視為係隱藏合法之借名登記契約，依民法第 87 條第 2 項規定，應依一般契約解釋其效力。詳參：陳聰富，脫法行為、消極信託及借名登記契約—最高法院九十四年度台上字第三六二號民事判決評釋，月旦法學雜誌，123 期，頁 231，2005 年；陳聰富，註 8，頁 303-308。

¹¹ 最高法院 98 年度台上字第 76 號判決、最高法院 99 年度台上字第 1114 號判決參照。

賴登記原則受保護之空間；亦有判決¹²採「折衷說」，認為出名人在名義上既為不動產所有權人，其處分行為縱有違反約定，除相對人係惡意之情形外，尚難認定為無權處分。

為解決上述見解歧異，最高法院作成 106 年度第 3 次民事庭會議決議，明確採「有權處分說」，統一實務立場。依該決議，不動產借名登記契約僅為借名人與出名人間之內部債權契約，其效力不及於第三人；出名人既已依法登記為不動產所有權人，其將不動產處分移轉登記予第三人之行為，自屬有權處分。此決議貫徹了不動產登記制度之公示性原則，並有助於維護不動產交易安全。

（三）學說見解

綜上可知，我國司法實務在處理不動產借名登記之問題上，呈現出一種對內出於私法自治原則之考量而寬認不動產借名登記契約為有效，不動產實質所有權人仍為借名人，出名人僅係登記名義人，並無管理、使用、收益、處分等等實質之所有權能；而在外部關係上，則基於不動產登記制度公信力和維護交易安全之價值判斷，認為出名人所為係有權處分之雙軌模式。而學界對於最高法院之見解亦多有批判，以下亦將分為內部效力和外部效力兩個部分進行學說上見解之歸納：

1. 內部效力

首先，關於借名登記契約之法律定性，學說上有認為¹³，自民法處理他人事務之規範體系出發，對最高法院長期以來將借名登記定性為「無名契約並類推適用委任規定」之見解提出質疑。蓋依民法第

¹² 最高法院 100 年度台上字第 2101 號判決參照。

¹³ 游進發，借名登記是信託且可能無效——以最高法院 107 年度台上字第 792 號民事判決為例，裁判時報，101 期，頁 35-39，2020 年；陳誼涵，不動產借名登記之法律關係，國立臺北大學法律學系法律專業組碩士學位論文，頁 22-31，2022 年。

529 條規定，關於勞務給付之契約不屬於法律所定其他種類者，應「適用」，而非「類推適用」委任之規定，此乃我國立法例採取「統一理論」之體現，亦即以事務處理為內容之契約均受此規範體系涵攝。借名登記之債權契約以出名人處理借名人事務為內容，其核心義務在於出名人提供登記名義並對外表示登記名義與真實相符。借名登記之債權契約因此符合信託法第 1 條信託契約之必要之點，應定性為信託契約，而非無名契約¹⁴。其認為縱使不將借名登記契約定性為信託，依民法第 529 條亦應直接「準用」委任規定，而非「類推適用」。

再者，對於實務上就借名登記契約有效性，即所謂「正當原因」之審查，學說上多認為其過於寬鬆。

有認為¹⁵，契約自由之限制分為兩個層面，一為內在本質之界限，即人性尊嚴。蓋姓名係識別權利主體之不可分割標誌，倘以借名契約將出名人純粹作為人頭或傀儡，完全剝奪其主體地位，則牴觸人性尊嚴，應屬無效；其二為外在法規範之限制，國家得以法律限制契約自由以維護公益，原住民保留地之身分專屬性即為典型，違反者依民法第 71 條無效。其認為應嚴格劃定借名登記契約自由之界限，違反人性尊嚴或強制禁止規定者應認定為無效。

亦有認為¹⁶，借名登記契約原則上應屬無效，其理由在於借名人多具不法之動機，且借名登記契約對於社會產生過大之外部成本，不

¹⁴ 認為借名登記契約應定性為財產信託之相同見解，可參：魏大曉，不動產借名登記法律關係內部與外部效力——契約自由界線與風險分配，月旦民商法雜誌，81 期，頁 61-85，2023 年。其認為委任契約之客體為受任人提供之勞力或服務，然出名人之角色僅係依物權法向地政機關申請登記，並非提供勞務；若將提供「姓名」解為提供勞力，更有將人格權作為交易客體之疑慮。其認為借名登記契約應定性為「財產信託」，契約之核心客體為財產權，借名人係將自己財產所有權移交予出名人管理。

¹⁵ 魏大曉，註 14，頁 67-70。

¹⁶ 黃健彰，不動產借名登記相關民事法律關係——以評析近年最高法院裁判為主，收於：民事裁判之理論實踐與民事法學之發展：孫森焱大法官紀念論文集，初版，頁 521-572，2025 年。相同見解，可參：郭松濤，談借名登記契約——兼評最高法院 98 年度台上字第 990 號判決，司法周刊，第 1579 期，頁 2-3，2012 年。

僅破壞不動產登記制度公示功能、損害債權人與繼承人權益、誤導公權力行使、影響財產申報正確性，以及導致政府大數據與實價登錄資料失真。因此，凡借名登記係為規避受讓人資格或稅捐者，應依民法第 71 條認定違反強制規定而無效；若係為逃避強制執行或騙取貸款者，則應依民法第 72 條認定違反公序良俗而無效。

2. 外部效力

而在出名人所為處分行為之外部效力上，學說見解呈現高度分歧，有論者¹⁷主張「無權處分說」，認為借名人僅移轉了「登記名義」，不動產之實質所有權並未移轉。出名人既無所有權，其處分行為自屬「無權處分」。

亦有論者¹⁸提出應依財產來源「類型化」區分說，倘財產係自第三人處取得（例如界名人出資買房並登記於出名人之名下），則移轉之物權行為係真實有效，出名人取得真正所有權，其處分即為「有權處分」；反之，若是「借名人移轉自有財產」（例如借名人將自己名下之房屋過戶予出名人），則雙方欠缺物權移轉的效果意思，借名人仍是真正所有權人，出名人的處分則為「無權處分」。

另有自「風險分配」之角度出發，支持最高法院前揭決議所採之「有權處分說」，並指出借名人往往係基於個人利益（如投機、逃稅）而捨棄合法之信託制度，選擇信任出名人，是應自行承擔人頭違約之絕對風險，而不應將風險轉嫁給第三人，其認為貫徹有權處分係現階段解釋論上所能抑制借名登記濫用之最佳手段。

此外，亦有基於相同理由，肯認實務所採「有權處分說」之見解，惟於第三人係惡意時，基於惡意不受保護之原則，應類推適用信託法

¹⁷ 蔡晶瑩，論借名登記契約／最高法院 100 台上 2101 判決，台灣法學雜誌，242 期，頁 176-178，2014 年。

¹⁸ 王千維，由最高法院一○六年度第三次民事庭會議決議看不動產借名登記，月旦法學雜誌，271 期，頁 28-38，2017 年。

第 18 條¹⁹之規定，給予借名人撤銷權²⁰。

三、代結論

（一）基於規避稅負之借名登記契約應屬脫法行為

綜上所述，關於不動產借名登記契約之定性、效力等等，學說和實務之爭議仍存。本文以為，暫且不論基於規避稅負而訂立之不動產借名登記契約在租稅法上之評價上究係「合法節稅」、「租稅規避」，抑或「逃漏稅捐」，蓋此尚須個案具體判斷。惟觀察納稅者權利保護法第 7 條第 3 項就租稅規避之定義²¹，和前揭民法學者對於「脫法行為」之定義高度契合，即納稅義務人透過私法法律形式之安排，規避租稅法規範。而實際上，在個案是否構成租稅規避之判斷上，本即需透過對於租稅法規範之解釋，來評價「規範是否存在漏洞」、納稅義務人是否「濫用」「非常規之法律形式」等等，因此，出於規避稅負之動機所訂立之不動產借名登記契約，應屬「脫法行為」無疑。然如前述，所謂脫法行為實係法律解釋之問題，關於借名登記契約私法上之有效性，仍需回歸個別租稅法規範之規範目的進行解釋、探討其是否有民法第 71 條、第 72 條規定之適用，不一而足。

（二）基於規避稅負之借名登記契約之有效性檢驗

¹⁹ 信託法第 18 條規定：「受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人得聲請法院撤銷其處分。受益人有數人者，得由其中一人為之。（第 1 項）前項撤銷權之行使，以有左列情形之一者為限，始得為之：一、信託財產為已辦理信託登記之應登記或註冊之財產權者。二、信託財產為已依目的事業主管機關規定於證券上或其他表彰權利之文件上載明其為信託財產之有價證券者。三、信託財產為前二款以外之財產權而相對人及轉得人明知或因重大過失不知受託人之處分違反信託本旨者。（第 2 項）」

²⁰ 陳聰富，同註 8，頁 307-308。

²¹ 按所稱「租稅規避」（Steuerumgehung），係納稅義務人採行租稅構成要件之文義所不能包括，而與所欲達成之經濟效果不相當之法律形式，以達成與實現租稅構成要件相同之經濟效果，從而脫免或減輕租稅負擔，參：陳敏，稅法總論，二版，頁 212，2023 年；柯格鐘，論稅捐規避行為之立法與行為的類型化，興大法學，第 15 期，頁 29-100，2014 年。而納稅者權利保護法第 7 條第 3 項亦明文：「納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。」

是以，出於規避稅負之動機，透過私法上借名登記契約法律形式之安排，規避租稅法規範之脫法行為，其效力，涉及「租稅法規範是否為民法第 71 條所稱強制或禁止規定」，通說將此處之禁止規定區分為效力規定和取締規定²²，並指出法律行為單純違反取締規定者，並非無效。惟其區別之基準，仍需回歸系爭規範本身之立法意旨是否在否認其行為之私法效力。學說上，民法學者在此多認為禁止規定旨在實現刑法或行政管制上之目的，而非規整當事人間之私法關係，且契約動輒無效將使當事人間返還請求等關係相當複雜，基此，賦予契約訴求力若未明顯牴觸禁止規定之規範意旨和價值判斷，即應將之認定為取締規定²³。

依此，租稅法規範通常係以私法概念說明所欲加以課徵租稅之經濟事項，然基於私法自治原則，人民為達成一定之經濟目的，而作成法律行為時，通常有多種方式供其自由選擇採行，而有多種法律形成之可能性。租稅法規範當然無意否定不以其所規範之形式實現經濟利益之法律行為之效力，因此，縱使有違租稅法律所定形式，至多僅能謂此處存有規範漏洞，而無從據此依第 71 條否認其私法行為之效力。

然而是否可將之涵攝至第 72 條之「公序良俗」，似非無疑。通說認為此處之「公共秩序或善良風俗」係指國家社會一般利益或道德而言²⁴，且應兼括整個法秩序的規範原則及價值體系²⁵。本文認為，在財稅法學界所歸納出，所謂國家課稅權限之行使，必須建立在合於人民基本權利保障，並能實現公平分配稅捐負擔、符合稅捐正義，透過法規範而加以實踐之基

²² 陳自強，註 7，頁 161-164；實務上，可見：最高法院 68 年台上字第 879 號判例、最高法院 71 年台上字第 4423 號判決。

²³ 參陳自強，註 7，頁 164。本文認為，如此使私法關係處理上能單純化，固非無見，惟公示制度、管制目的是否真能達成？毋寧應比照瑕疵共同理論，全部無效。

²⁴ 最高法院 69 年台上字第 2603 號判例：「民法第 72 條所謂法律行為有背於公共秩序或善良風俗者無效，乃指法律行為本身違反國家社會一般利益及道德觀念而言。本件被上訴人雖違反與某公司所訂煤氣承銷權合約第 6 條規定，以收取權利金方式頂讓與第三人，但究與國家社會一般利益無關，亦與一般道德觀念無涉，尚不生是否違背公序良俗問題。」

²⁵ 王澤鑑，註 6，頁 342。

礎上之稅捐法秩序一體性²⁶，及所追尋之所有人依其經濟負擔能力平等地繳納稅捐之租稅公平、租稅正義之角度而言，應可認為係此處整體法秩序之規範原則、價值體系，從而屬於第 72 條之「公共秩序」。

又如前揭學說認為借名登記對於整體社會成本、乃至於不動產公示制度之危害，晚近更有下級審普通法院²⁷於判決附件中明確指出，我國盛行之不動產借名登記契約，實際上係「分裂所有權」，對於不動產物權之制度產生危害，總結以上租稅法秩序、不動產登記制度等等，至少足認出於規避稅負之不動產借名登記契約係悖於公共秩序，而依第 72 條規定無效。

退步而言之，縱使依照多數見解，認為不動產借名登記契約仍係有效。然實務在最高法院 106 年度第 3 次民事庭會議決議後，基本確立了出名人和借名人之間訂立之不動產借名登記契約，其效力不及於第三人，以維護不動產公示公信和交易安全之價值判斷。亦即，最高法院雖然認為在不動產借名登記契約之內部關係中，實質所有權人仍為借名人，出名人僅係登記名義人，並無管理、使用、收益、處分等等實質之所有權能；僅係在外部關係上，基於上述價值判斷，而認為此等借名登記契約之效力並不及於第三人，縱此第三人係惡意亦同，蓋此際為「有權處分」。

本文認為，順著最高法院之邏輯而言，既然可出於不動產登記制度、交易安全維護、遏制借名登記等等考量，而作出此價值判斷，認為其內部借名關係效力不及於外部之第三人，則同為外部關係之國家租稅債權，基於租稅公平、國家財政等等公益事由之考量，似乎亦不應受其借名登記契約之效力所及。

參、不動產借名登記返還之實體法定性

²⁶ 柯格鐘，稅捐法秩序，頁 144-145，2023 年。

²⁷ 臺灣桃園地方法院 110 年度訴字第 1927 號判決參照。

一、房屋、土地「取得日」之認定與實益

揆諸房地合一稅新制之適用範圍，按所得稅法第4條之4第1項規定²⁸、房地合一課徵所得稅申報作業要點（下稱作業要點）第2點²⁹，105年1月1日以後「取得」之房屋、土地，其交易所得應依第14條之4至第14條之8及第24條之5規定課徵所得稅。而關乎新制稅率之「持有期間」計算，依照作業要點第5點，係自房屋、土地「取得之日」起算至交易之日止。是以，關於所謂房屋、土地「取得日」之認定，至少存在「是否為房地合一稅新制之適用範圍」以及其「持有期間自何時起算」此兩大實益。

依此，關於房屋、土地「取得日」之認定即至關重要。依作業要點第4點本文，原則上係以「完成所有權移轉登記日為準」。如此認定，亦契合民法第758條關於物權變動之生效要件採登記主義之價值體系。

是以，本件實體上最主要之爭點³⁰即在於，原告甲得否透過主張其自90年出資購得A房地時起，即為實質所有權人，106年之所有權移轉登記僅係A房地借名登記返還，而不應被認定為係重新取得而切斷其持有期間，原處分就持有期間計算有誤，從而本件即非屬房地合一稅新制適用範圍。

二、借名登記返還得否切斷持有期間之計算

²⁸ 所得稅法第4條之4第1項：「個人及營利事業交易中中華民國一百零五年一月一日以後取得之房屋、房屋及其坐落基地或依法得核發建造執照之土地（以下合稱房屋、土地），其交易所得應依第十四條之四至第十四條之八及第二十四條之五規定課徵所得稅。」

²⁹ 房地合一課徵所得稅申報作業要點第2點：「個人及營利事業交易一百零五年一月一日以後取得之房屋、土地，應依本要點規定計算房屋、土地交易所得，課徵所得稅。個人及營利事業交易一百零五年一月一日以後取得以設定地上權方式之房屋使用權或預售屋及其坐落基地，該交易視同前項之房屋、土地交易。……」

³⁰ 然而，高雄高等行政法院這兩則判決中，法院駁回原告之主張皆係以其「無法證明借名登記關係確實存在為由」，似乎係肯認倘原告能提出具體事證證明借名登記關係存在，即可承認其關於取得日之主張；惟本文對此則持相反見解，而認為縱使原告能證明其移轉係基於借名登記返還之原因，仍無從推翻取得期間之認定。是以，系爭「借名登記返還得否切斷持有期間之計算」即為主張一貫性所應處理，蓋原告所主張系爭移轉乃基於借名登記關係返還所為，惟縱其主張為真，仍無從推翻關於取得日之認定，詳本文後述。

（一） 財政部台財稅字第 10404514520 號令之濫觴

蓋房地合一稅新制乃基於延續早期特銷稅防杜房產投機炒作之目的而立，因此相關爭議或應追溯至特銷稅時期之相關規範措施尋求解方。而此「借名登記返還得否切斷持有期間計算」爭議之濫觴，即係源自財政部就特種貨物及勞務稅條例第 5 條第 1 項第 12 款規定「確屬非短期投機」之案件類型，而於 104 年 2 月 5 日頒布之台財稅字第 10404514520 號令，其中第 7 點指出：「所有權人銷售因借名登記經出名人返還之不動產，所有權人及出名人持有該不動產期間合計逾二年者。」

自特銷稅之立法目的和實質課稅原則之解釋而言，系爭函釋允許合併計算出名人與所有權人的持有期間，似亦有其正當性和法理基礎。蓋於借名登記關係存續中，不動產之管理、使用、收益、處分等等所有權能自始皆存於借名人身上，從而當出名人將登記名義返還予借名人時，民法上雖係一所有權移轉登記之物權行為，但在經濟實質上，並未產生跨越不同主體之變動。而既然經濟實質並未變動，稅法上即將其視為所有權之延續，因而允許將出名人掛名的期間，計入借名人之持有期間。且特銷稅和房地合一稅之立法目的皆在抑制短期買賣炒作之投機行為，倘若借名人和出名人合計持有該不動產的時間已經超過法定門檻，客觀上就證明了這筆房地是被長期持有的，並非藉由頻繁轉手來賺取短期差價的投機客，稅捐稽徵機關當然應將這段借名期間合併計算，給予免徵或較輕稅率的待遇。

（二） 本文見解：

然而，本文以為財政部 104 年函釋之見解實有過度向納稅義務人經濟實質妥協之嫌，而似有未洽，詳言之：

1. 經濟實質已然產生變動

首先，依現行通說和實務之見解，在不動產借名登記契約之內部關

係，對系爭不動產享有管理、使用、收益等所有權能之人固仍係借名人而非出名人，然而，實質上享有「處分」權能之人，是否仍係借名人？本文持高度懷疑，蓋實務上所見借名登記返還相關訟爭，皆係源自出名人擅自將借名之不動產處分掉，抑或出名人不願返還登記予借名人或其繼承人。因此自經濟實質而言，難認為其未產生任何變動³¹。

此外，法律行為無效，或嗣後歸於無效，而當事人仍使其經濟效果發生，並維持其存在者，並不影響租稅之課徵。良以稅法所欲掌握者，乃表現納稅能力之經濟事實，而非該經濟事實之法律外觀，行政法院 82 年 9 月份庭長、評事聯席會議參照。是以，倘若依本文見解將不動產借名登記契約認定為無效，依照實質課稅原則，結論上亦無不同。

2. 租稅公平和法秩序一體性之考量

再者，自法學方法而言，例外本應從嚴解釋，民法第 758 條既已確立物權之變動係以登記主義為原則，而所得稅法和作業要點之規定亦遵循此原則。出名人既選擇以不動產借名登記契約之方式，於平時充分享受隱匿經濟實質的紅利與法規規避之便，卻在面臨房地合一稅負時，主張應例外實質課稅原則穿透不動產之登記外觀以適用較有利之持有期間。不僅破壞不動產登記制度之公信力，對於採取誠實登記外觀之其他納稅義務人形成橫向不公，且借名登記契約相關之事實證據具高度隱匿、不易舉證且偏在納稅義務人之特性，因此無論於稽徵程序、抑或民事、行政審判程序之證據調查上，勢必將耗費大量行政、司法之資源，造成調查、稽徵之成本外部化之結果。因此，本文認為，借名人既擇以借名登記契約之私法形式，即應承擔返還時被認定為移轉取得之稅法評價及相應不利益，而不應允許其濫用實質課稅原則，造成登記制度和租稅公平之破毀。

³¹ 當然，此種將所有權能割裂觀察之角度似有違背所有權能之本質，惟此現象乃借名登記之本質所致，而其對於現代所有權概念之破毀，亦係本文認為應全面否定不動產借名登記契約之原因。

三、實務上就取得日認定之關鍵在於「權利延續性」

(一) 實務上關於取得日認定之案例歸納

實際上，觀察行政法院就房地合一稅「取得日」相關認定之各類不同案型，可以將之整理、歸納為以下結果：

1. 市地重劃後之增配土地

按平均地權條例第 62 條本文：「市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之土地，自分配結果確定之日起，視為其原有之土地。」實務³²上認為平均地權條例第 62 條本文雖規定重劃後分配的土地「視為原有土地」，惟僅限於「交換分配」、即原有土地變形後之部分，而不包含超額增配或價購的部分。如果地主透過差額地價或購買抵費地額外付錢所取得的土地，此部分不具備原有土地之代位性，既非原有土地之延伸，自屬新取得之土地，其取得日認定均以「所有權移轉登記日」為準。

2. 經廢止徵收後發還之土地

實務見解認為³³，在一般徵收之情形，土地經徵收發放補償費完竣時，所有權即歸屬國家，且依照土地徵收條例第 51 條第 2 項繳納補償取回被徵收之土地係具選擇權。故一般徵收後經「廢止徵收」而取回之土地，其取得日依財政部台財稅字第 11104647190 號令³⁴，應為「核准廢止徵收日」。

3. 繼承土地合建分屋

³² 最高行政法院 112 年度上字第 130 號判決、高雄高等行政法院高等庭 108 年度簡上字第 69 號判決參照。

³³ 臺北高等行政法院地方庭 113 年度地訴字第 190 號判決、高雄高等行政法院地方庭 113 年度地訴字第 101 號判決參照。

³⁴ 財政部 111 年 10 月 6 日台財稅字第 11104647190 號令：「核釋個人交易 105 年 1 月 1 日以後依土地徵收條例經廢止徵收發還之土地，依所得稅法第 4 條之 4 及第 14 條之 4 規定計算土地交易所得，該土地之取得日、持有期間及取得成本認定如下：一、原土地所有權人交易其領回土地：(一) 土地取得日以原核准徵收機關核准廢止徵收日為準。(二) 土地持有期間之計算，以核准廢止徵收日起算至交易日止之期間，與該土地被徵收前原所有權人取得土地所有權移轉登記日起算至徵收日止之期間，合併計算。(三) 土地取得成本，以原土地所有權人依土地徵收條例第 51 條規定繳清應繳納之價額為準。但該土地被徵收前之原始取得成本高於上開應繳納價額，並提示相關證明文件者，以原始取得成本為準。」

行政法院認為³⁵，土地所有權人以其自有之土地和建商合建所分得之房屋，其本質上係以相當價值之土地交換而來，具有原有土地替代物或代位物之性質。而既然合建所分得之房屋在稅法上被視為原有土地之延續，且繼承發生時點並非人為可控，那麼在計算繼承人出售該合建房屋的持有期間時，自應溯及合併計算「被繼承人持有原自有土地的期間」。

透過上述實務見解類型化之結果後可知，當涉及不動產之重劃、徵收發回、合建等等財產狀態產生改變之情形時，行政法院會著重檢驗其新生權利是否為舊有權利之延伸，以及系爭財產狀態之改變是否係所有權人自己行為所致。若係基於原有權利之代位、延伸，實務原則上肯認追溯其持有期間；但若係額外出價（例如繳納差額、購買抵費地）取得的部分，則會被認為係「新取得」。

（二） 不動產借名登記之返還不具「權利延續性」

綜上所述，實務就房地取得日之認定，原則上皆遵循民法第 758 條之「登記主義」，即以「完成所有權移轉登記日」為準，而不受當事人間債權契約原因關係所影響，蓋移轉登記相較於債權契約具有公示性且既明文為物權變動生效時點，亦較符合稅捐債權關係需明確其成立時點之特徵。儘管實務發展上例外承認在具備「權利延續性」和「非由所有權人自己行為所致」此二要件之情形下，可將其持有期間追溯合併計算。

惟本文認為，於民事法上觀點而言，自不動產借名登記關係有效存在時起，借名人「對外即非所有權人」，其就不動產雖仍有實質之管理使用收益之權能，然而，其「處分」之權能早已移轉予出名人，否則豈生最高法院 106 年度第 3 次民事庭會議決議，出名人對外所為處分行為係「有權處分」之見解。是以，依現行實務多數之見解，借名人物權上之「處分權能」毋寧早已質變為僅得對出名人主張之借名登記返還請求權，從而難謂其對於房地之

³⁵ 最高行政法院 112 年度上字第 583 號判決參照。

所有權能仍具延續性。

退步言之，縱認為借名人基於內部契約關係而得對出名人主張之返還請求權乃其原先所有權能之代位、變形，惟造成此種狀態之改變，仍係由出名人和借名間可控之契約關係所由致，從而仍不符合實務見解所要求之要件。

四、 小結：借名登記返還應被認定為係移轉取得

綜上，前揭財政部 104 年函釋雖以「經濟實質未變、非屬短期投機」為由，放寬借名登記經出名人返還得合併計算持有期間。惟本文認為，基於「經濟實質之觀察」、「不動產登記制度公信力維護」、「租稅公平之維護」等原因，即使所有權之移轉係基於借名登記返還之原因關係，於稅法上取得日之認定上並不因之受影響，從而自無從主張合併追溯計算其持有期間。是以，本件原告縱能確實證明 106 年之所有權移轉係出於不動產借名登記之返還，其實體上之主張亦屬無理由，如此，亦無庸再就借名關係之存否為不必要且曠日廢時之證據調查。

總結而言，無論在特銷稅抑或房地合一稅之適用上，皆應嚴守不動產登記之生效時點。納稅義務人既選擇隱於登記制度背後，即應自行承擔持有期間被切斷之稅法上不利益。蓋唯有嚴格確立此一準則，方能防堵假借名登記規避稅負，並促使納稅義務人誠實揭露、登記名下之不動產，從根本上健全不動產市場之透明度與房地合一稅制之公平性，並根絕我國長年以來因借名登記契約所衍生之巨量訟爭。

肆、 民事判決對稽徵程序之拘束力

一、 審判二元化體系與民事判決既判力

一。

二、 實務見解

(一) 一

一。財部 92 年 2 月 19 日台財稅字第 0920451458 號函

(二) 二

二。

三、 三

三

伍、 結論

綜上所述，本文認為借名登記本質上與現代法制之體系發展有所扞格，而不應廣泛承認其效力。蓋借名登記之法律關係極為複雜，加之當事人間舉證難度等等因素考量，普通法院之訴訟資源亦遭借名相關案件濫用，土地登記公示制度乃至於相關土地、建物管制之規範亦多遭架空，是以正本清源之解方，毋寧係在私法上即將之依民法第 72 條解釋為「無效」之法律行為，自根源杜絕紛爭。

至於在稅法上，本文認為縱使依照現行實務見解，認定不動產借名登記契約係有效，惟借名登記關係解消後之返還，性質上仍應認定為係一次全新之移轉，理由有二：

首先，雖曰借名關係中，借名人方為實質所有權人，出名人僅有登記名義之外觀，而無管理使用收益處分之權能，惟出名人移轉所有權登記與第三人係有權處分，由此而起之民事訟爭亦不在少數，因此，出名人應具處分之權能，從而經濟實質上，即屬再一次之移轉。

此外，唯有如此解釋，方能貫徹不動產登記公示制度之公信力，並與最高法院之見解為相一致之判斷，並且避免稽徵成本外部化。

因此，於本件案例中，根本無庸浪費訴訟資源審酌原告就借名關係之主張，行

政法院以其主張欠缺一貫性，依行政訴訟法第 107 條第 3 項第 2 款規定，以「顯無理由」駁回即可。

參考文獻

一、專書

王澤鑑，民法總則，修訂新版，2021 年。

柯格鐘，稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則，2023 年。

陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，五版，2023 年。

陳敏，稅法總論，2 版，2023 年。

陳聰富，民法總則，三版，2021 年。

二、碩博士論文

陳誼涵，不動產借名登記之法律關係，國立臺北大學法律學系法律專業組碩士學位論文，2022 年。

三、專書論文

黃健彰，不動產借名登記相關民事法律關係—以評析近年最高法院裁判為主，收於：
民事裁判之理論實踐與民事法學之發展：孫森焱大法官紀念論文集，初版，
2025 年。

四、期刊論文

王千維，由最高法院一〇六年度第三次民事庭會議決議看不動產借名登記，月旦
法學雜誌，271 期，2017 年。

柯格鐘，論稅捐規避行為之立法與行為的類型化，興大法學，第 15 期，2014 年。

郭松濤，談借名登記契約—兼評最高法院 98 年度台上字第 990 號判決，司法周刊，
第 1579 期，2012 年。

陳聰富，脫法行為、消極信託及借名登記契約—最高法院九十四年度台上字第三六
二號民事判決評釋，月旦法學雜誌，123 期，2005 年。

游進發，借名登記是信託且可能無效——以最高法院 107 年度台上字第 792 號民事判決為例，裁判時報，101 期，2020 年。

蔡晶瑩，論借名登記契約／最高院 100 台上 2101 判決，台灣法學雜誌，242 期，2014 年。

魏大曉，不動產借名登記法律關係內部與外部效力——契約自由界線與風險分配，月旦民商法雜誌，81 期，頁 61-85，2023 年。

五、研究計畫

柯格鐘，借名行為之課稅，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫報告，計畫編號：NSTC 113-2410-H-002-147，2025 年。

曾中信，台灣房地產資本利得稅之研究：有效稅率與累進性之分析，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫報告，計畫編號：NSTC112-2410-H031-074，2024 年。